

1501180-68.2020.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... Infância e da Juventude por ato infracional equiparado ao tráfico e já foi condenado em Pindamonhangaba (ainda sem trânsito), por tráfico.

Verifica-se, assim, que o réu não se trata de pequeno traficante, indicando que seu envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes é profundo, o que afasta a aplicação da causa de diminuição.

A alegação de que atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1501180-68.2020.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501180-68.2020.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE ANAIA ROMAO

Vistos.

Paulo Henrique Anaia Romão foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 12 de novembro de 2020, por volta das 11h40min, na Rua Sebastião Joemil Dias, nº 131, B. Bonfim, nesta cidade de Taubaté, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava e trazia consigo para fins de venda e entrega a terceiros consumidores, 10 porções de "Cannabis Sativa L", conhecida como maconha, com massa líquida de 58,52 gramas e 5 pedras de crack, subproduto da cocaína, com massa líquida de 0,76 gramas, substâncias causadoras de dependência física e psíquica.

Sustenta o Ministério Público que, na manhã do dia dos fatos, agindo como era de costume, o réu levou consigo certa quantidade de drogas escondidas dentro de uma pochete e se deslocou até o endereço mencionando acima, onde realizou a venda dos entorpecentes.

Ocorre que, durante patrulhamento de rotina, ao notar a presença da viatura, o réu empreendeu fuga e dispensou a pochete ao solo e durante a fuga saltou vários

alambrados, vindo a invadir uma residência para se esconder dos policiais, onde foi abordado e preso em flagrante, dentro de um quarto.

Na pochete dispensada pelo réu, foram encontradas em seu interior 10 porções de maconha, 5 pedras de crack e a quantia de R\$ 85,00 em notas trocadas, auferido com o tráfico, tendo confessado os fatos aos policiais.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 82/84.

Citado (fls. 113), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 117.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Carlos Henrico dos Reis Gracato e Paulo Randerson Novais de Oliveira, procedendo-se ao interrogatório do réu, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Em juízo, os policiais confirmaram os fatos e todas as circunstâncias, narrando que visualizaram o réu e ele fugiu, dispensando uma pochete e se escondendo em uma residência, onde foi detido. Interrogado, o réu negou a prática delitiva, justificando que era usuário e comprou os entorpecentes para consumo, versão que não encontra amparo no conjunto probatório, considerando a apreensão das drogas, a confissão na fase policial, os testemunhos dos policiais e as diversas passagens anteriores, inclusive quando menor de idade. Requereu a condenação nos exatos termos da denúncia. Na primeira fase, sendo o réu tecnicamente primário, com maus antecedentes e diversas passagens e condenações na Vara da Infância e Juventude, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, há a atenuante da confissão, na fase policial, e a menoridade. Anotou que o regime deve ser o fechado, diante da reincidência e vida dedicada ao tráfico de drogas, o que também afasta a aplicação do redutor, previsto no artigo 33, § 4º, indicado ao pequeno e eventual traficante, o que não se dá no caso concreto.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu como medida de rigor. Ouvidos em juízo, os policiais confirmaram a versão apresentada na Delegacia, de que visualizaram o réu na presença de outros indivíduos e que ele fugiu, sendo surpreendido no interior de uma residência, após breve perseguição. Nesse sentido, anotou que as explicações fornecidas não condizem com a versão do réu e demais elementos de prova. É fato que ele apresentava diversas lesões, constatadas por meio de laudo pericial, e tais lesões constaram em seu depoimento na Delegacia. Ressaltou que, em tal interrogatório, embora estivesse narrando a posse das drogas em primeira pessoa, com relação às lesões a narrativa não é a mesma, o que demonstra a possibilidade de ter sido proferida por terceira pessoa e não pelo réu, de forma a ditar o que deveria ser escrito. Em concordância, na presente audiência, o réu negou a prática delitiva, alegando que adquiriu drogas para consumo e assumiu a traficância diante do temor causado pelos policiais, indicando que sua versão é crível e plausível. Além disso, manifestou-se sobre a ausência de identificação e coleta de depoimento da pessoa cuja casa teria sido invadida, inclusive porque conversaram com ela, mas não a levaram à Delegacia, ainda que para eventual registro do delito de invasão de domicílio. Nesse cenário, a versão do réu de que tenha sido abordado e agredido do lado de fora da residência demonstrou-se mais condizente com a realidade. Caso o entendimento não seja este, postulou a desclassificação para a conduta de porte para uso próprio. Em eventual fixação de pena, pediu que a pena-base seja fixada em piso mínimo legal, observando que ao tempo dos atos era primário e sem antecedentes criminais. Destacou, também, que o réu é menor de 21 anos e há a confissão extrajudicial, em consonância aos

depoimentos policiais, fatos que devem ser utilizados para cálculo da pena. Ademais, afirmou que a quantidade e qualidade dos entorpecentes não divergem do normalmente esperado em situações semelhantes. Solicitou que seja aplicado o redutor em patamar máximo, uma que eventuais passagens pela Vara da Infância e Juventude, por serem pertinentes a atos infracionais, não podem ser consideradas para afastamento do benefício. Por fim, pleiteou o estabelecimento do regime aberto, com substituição da pena e dispensa do recolhimento de custas e despesas processuais.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não há questões preliminares a se enfrentar. As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), termos de depoimentos (fls. 2/3), termo de interrogatório (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo pericial provisório (fls. 16/20), fotografias (fls. 28/29), laudo pericial definitivo (fls. 96/98) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Carlos Henrico dos Reis Graçato, ouvida em juízo, informou que estavam em patrulhamento na região, quando se depararam com o réu e ele empreendeu fuga ao visualizar a viatura. Na ocasião ele estava portando uma pochete, a qual dispensou durante a breve perseguição, sendo constatada a existência de diversos entorpecentes dentro dela. No momento, ele pulou vários alambrados e invadiu uma residência, onde se escondeu atrás de um guarda-roupa de um dos cômodos. Franqueada a entrada pela proprietária, eles fizeram a prisão do réu. Questionado, ele confessou que estava na mercancia ilícita para seu sustento. Em conversa com a dona da residência, ela disse que não o conhecia, só viu o momento em que ele entrou correndo em sua casa.

A testemunha Paulo Randerson Novais de Oliveira, ouvida em juízo, narrou que estavam em um condomínio quando se depararam com o réu e mais alguns indivíduos, os quais empreenderam fuga ao avistar a viatura. Na oportunidade, o réu pulou um alambrado e, logo após, o muro de uma residência, dispensando a pochete, a qual ele prontamente pegou e encontrou uma quantidade de maconha. Quando saiu de dentro do condomínio o outro policial se dirigiu à abordagem do réu dentro da casa, por relato da proprietária, fazendo sua prisão.

O réu Paulo Henrique Anaia Romão, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e negou que seja verdadeira. Justificou que estava na casa da namorada e foi ao encontro de um traficante para comprar drogas para seu consumo, momento em que a viatura apareceu e ambos saíram correndo. Alegou que já havia entregado o dinheiro para o vendedor, sendo uma quantia de R\$ 50,00, e não possuía qualquer entorpecente em sua posse, todavia, empreendeu fuga por medo, uma vez que já possui passagens anteriores por tráfico. Na ocasião, o traficante dispensou a pochete que possuía as drogas. Nesse contexto, correu e se escondeu em uma residência, mas logo foi encontrado pelos policiais, os quais o ameaçaram de morte caso não assumisse a propriedade dos entorpecentes. Narrou, ainda, que

durante a perseguição, os policiais deram um soco em seu rosto e pisaram em sua barriga, além de socos em seu braço. Disse ser solteiro, ter 1 filha, que mora com a mãe; trabalhava com o pai fazendo carretos, com renda média de R\$50,00 por dia; tem outros processos por tráfico, inclusive, preso por um desses processos.

Bem provadas a autoria e a materialidade relativamente ao delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, que reza:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

Do arcabouço probatório não se tem dúvida de que os fatos atinentes ao tráfico se passaram na forma como narrado na denúncia, rendendo ensejo à necessária certeza que ora embasa o édito condenatório.

Verifica-se que a conduta do réu se enquadra nos verbos-núcleo do tipo penal, notadamente transportar e trazer consigo drogas, resultando, assim, configurada a tipificação do crime em comento.

Como confirmado pelos policiais ouvidos, em relatos coesos e firmes, o réu correu ao avistar a viatura e, na fuga, jogou ao solo a pochete que carregava, na qual se encontravam as drogas e o dinheiro.

A quantidade da droga e a forma como embaladas não deixa dúvida de que à traficância se destinava.

Registre-se, por relevante, que o depoimento dos policiais no sentido da apreensão da droga em poder do réu reproduz, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalta-se que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Some-se a isso, a própria confissão do réu na delegacia.

Sabido que na oportunidade de seu primeiro interrogatório os fatos estão vivos na memória e, muitas vezes em razão da surpresa e do curto espaço tempo decorrido entre o fato e a oitiva, a verdade vem à tona, sem que tenha tempo hábil para que o

acusado formule teses defensivas, desviadas da sinceridade.

Nesse passo é que entendem os tribunais que a confissão vale por seu próprio teor, e não pelo lugar onde é prestada.

“Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. Processual Penal. Prova. A delação do correu deve ser considerada como prova, sempre que ele assume sua participação na empreitada, não tentando se eximir de sua responsabilidade”(TJSP, Apelação Criminal nº 0007584-73.2009.8.26.0400, Rel.Des. Souza Nery, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/11/2012).

Quanto às teses defensivas, nenhuma delas é capaz de afastar sua responsabilidade.

Como acima apontado, as provas são robustas a incriminar o réu e consistem nos relatos seguros dos policiais, que se somam ao próprio encontro das drogas dentro da pochete por ele dispensada, fato que foi visualizado pelos policiais.

Nada obstante, impende o registro de que não há qualquer conflito com os elementos colhidos e as lesões apresentadas pelo réu se deram por ele haver atravessado alambrados na tentativa de fuga, momento em que caiu e se machucou, como por ele afirmado na delegacia, versão que se afigura verossímil.

O fato de não se ter levado a dona da casa em que o réu se escondeu para testemunhar na delegacia não se afigura relevante, pois a medida não se mostrava imprescindível, mesmo porque ela somente avistou a prisão do réu, fato irrelevante para a configuração do delito, e o réu não negou em nenhum momento o ingresso na residência para se esconder dos policiais.

Ademais, se o depoimento de tal pessoa fosse revelante, poderia a Defesa tê-la arrolado no momento pertinente, providência que não levou a efeito.

A propósito da questão, cabe o registro que a entrada do réu na casa de terceiro quando da fuga não configurou invasão de domicílio, pois ausente o dolo, o que também justifica o não encaminhamento da proprietária da casa para a delegacia.

Quanto à alegação de que a frase foi ditada por terceiro – o que, no entender da Defesa comprovaria que o réu estava falando a verdade – não se sustenta.

Como é cediço, o interrogatório no meio policial é registrado pelo escrivão, sob a presidência do Delegado de Polícia, e, em muitos casos, os escrivães não prezam pelo registro com a utilização de linguagem escorreita, verificando-se alguns equívocos que, contudo, não malferem a colheita do depoimento, assim como o seu teor.

Com relação à confissão, há de ser considerada como atenuante, tal qual a menoridade relativa.

Com relação à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/06, registro que não é o caso de reconhecê-la.

Isso porque a redução prevista na lei busca alcançar e tem por finalidade aquele pequeno traficante. É a ele que a lei visa a conceder a benesse, promovendo-lhe uma nova chance para que se ajuste ao meio social em que vive.

No caso em exame, o réu já foi condenado por 2 vezes perante a Vara de Infância e da Juventude por ato infracional equiparado ao tráfico e já foi condenado em

Pindamonhangaba (ainda sem trânsito), por tráfico.

Verifica-se, assim, que o réu não se trata de pequeno traficante, indicando que seu envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes é profundo, o que afasta a aplicação da causa de diminuição.

A alegação de que atos infracionais não são crimes e, por isso, não podem ser considerados para afastar o redutor não se sustenta. Isso porque os registros são elementos seguros que indicam o envolvimento do réu com a traficância e que se dedica a atividades criminosas.

Nesse sentido a jurisprudência.

“(...) 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ AgRg no REsp nº 1560667/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 17.10.2017, DJe 23.10.2017. No mesmo sentido: STJ AgRg no REsp 1653501/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 09.05.2017, DJe 17.05.2017; e STJ HC nº 299.673/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.08.2016, DJe 24.08.2016.

Estabelecida a responsabilidade, passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nélson Hungria e obediente à individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social da agente.

A quantidade de droga apreendida é pequena e não pesa em desfavor do réu.

No que se refere à personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) - se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa - que não é absoluta - demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão

equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo " A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarividente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais comezinhos da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis, publicado na rede mundial de computadores, no endereço <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaco-reis/958>).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demaís disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademaís, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre

Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decísum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo "fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime" (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3.^a Vara, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1.^a Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

"E escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, "nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo", demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019).

No que respeita à culpabilidade, o que se vê é natural à espécie.

O réu é primário.

Acerca da conduta social do réu não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Considerando-se a personalidade negativa do réu, eleva-se a pena mínima em 1/6, fixando-se a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, há a presença da atenuante da confissão e da menoridade relativa do réu que, contudo, não pode levar a pena aquém do mínimo em razão do disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Não há, também, circunstância agravante a ser considerada, razão pela qual a pena é atenuada para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento, fixada a pena definitivamente em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento será o fechado.

Trata-se de condenação pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta também exige maior rigor por parte do Estado, cabendo ser ressaltado que o crime foi perpetrado em plena via pública, à luz do dia, durante a pandemia que assola o mundo.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, a par da quantidade da pena, a medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do direito. Ademais, levando-se em conta, mais uma vez, a gravidade in concreto do crime, insuficiente seria sua aplicação, com fundamento no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Incabível, outrossim, a suspensão da pena prevista no artigo 77, em razão da reprovabilidade e da perniciosidade da conduta da traficância, bem como por afrontar o espírito da Lei 11.343/06, que em seu artigo 44, veda a concessão de sursis.

Anote-se, ainda, que a despeito da Resolução n 5, do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no §4.º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a conversão e o sursis não se fazem adequados à prevenção e repressão do crime em espécie, pois, como já se decidiu, "os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com reação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal,

qual seja, 'os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente' (TJSP, apelação 0026205.40.2008.8.26.0405).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes - 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal.

Anoto que, com relação ao dinheiro, não foi comprovado que advinha de lícito labor, impondo-se o seu perdimento.

Registro que seriam fatos de prova relativamente facilitada. Prova documental, no caso concreto, seria a única hábil à comprovação das alegações, mas não veio para os autos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal. Indefiro, contudo, a gratuidade da justiça por não haver qualquer prova acerca da afirmada hipossuficiência do réu, ausente provas de que a Defensoria Pública tenha realizado triagem socioeconômica.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para condenar o réu Paulo Henrique Anaia Romão à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 7 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA